

1500856-88.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... atividades criminosas, fazendo do narcotráfico meio de subsistência, verdadeiro profissional do tráfico. Tal circunstância também é provada pelas passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas. Assim, o acusado não preenche todos os requisitos legais da referida minorante. Pelos mesmos motivos, o regime prisional ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500856-88.2021.8.26.0571 - Controle 2021/000887

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN WESLLEY PRESTES FERRAZ

Data da Audiência:

17/02/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Kevin Wesley Prestes Ferraz. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Luciano Donizeti Rodrigues da Silva e Osny Benedito de Moraes Júnior arroladas pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Renato Coelho de Oliveira e a Defesa desistiu da oitiva de Valter Prestes Ferraz, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida o ré foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 17h30, na Rua Mario Barros de Moura, nº 8, Vila Prado, nesta cidade e comarca de Itapetininga, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para comercialização a terceiros, 35 (trinta e cinco) microtubos de cocaína, com peso líquido de 3,67g (três gramas e sessenta e sete centigramas), 281 (duzentos e oitenta e uma) pedras de "crack", com peso líquido de 68,61g (sessenta e oito gramas e sessenta e um centigramas), 09 (nove) porções de "maconha", com peso líquido de 60,68g (sessenta gramas e sessenta e oito centigramas), e 05 (cinco) porções de "skunk", com peso líquido de 5,02g (cinco gramas e dois centigramas), substâncias entorpecentes que

determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 106) e apresentou defesa prévia (fls. 110/111). A denúncia foi recebida em 30/09/2021 (fls. 112/113) e o acusado foi citado (fls. 102). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 02/03), auto de constatação (fls. 10/13) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 89/93). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu disse trazia consigo um "kit" de "crack", contendo cerca de 24 porções da droga, tudo destinado ao comércio. Contou que o restante da droga estava em sua casa. Disse que confessou aos policiais ter droga armazenada em sua habitação. Falou que o cão farejador localizou o entorpecente (fls. 25). Interrogado em Juízo, o réu voltou a admitir a prática criminosa. Afirmou que passava por dificuldades financeiras e teve que apelar para o tráfico. A prova oral também é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento por local conhecido como ponto de venda de drogas, momento em que avistaram o denunciado saindo de uma casa. Ocorre que, ao perceber a presença policial, KEVIN assustou-se e, diante disso, os policiais decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, os policiais encontraram com o denunciado 20 (vinte) porções de "crack", sendo que, indagado, KEVIN confirmou que havia mais drogas no interior da residência. Assim, em continuidade às diligências, os policiais militares solicitaram o apoio do canil e, com a ajuda do cão farejador, encontraram em uma estante no quarto 35 (trinta e cinco) microtubos de cocaína e 05 (cinco) porções de "skunk". Em uma lata de lixo na cozinha localizaram 09 (nove) porções de "maconha" e uma balança de precisão. Enterradas na parte da frente do imóvel foram localizadas 181 (cento e oitenta e uma) pedras de "crack". Por fim, em um buraco em um tijolo localizaram mais 80 (oitenta) porções de "crack". Diante disso, KEVIN foi preso em flagrante delito. Pois bem. Agora, o policial militar Luciano afirmou que patrulhavam o local quando viram o acusado - conhecido como empreendedor do tráfico - que, assustado, motivou a abordagem. Na revista pessoal foram encontradas 20 (vinte) porções de "crack". O réu, então, afirmou que abrigava mais drogas em sua moradia. Adentraram a residência e as demais drogas descritas na denúncia foram encontradas. Também foi apreendida uma balança de precisão. As drogas foram encontradas em locais diversos, inclusive com o auxílio do canil. O policial militar Osni fez coro às palavras do seu colega. Assim, a prova é firme ao incriminar o acusado. As circunstâncias da apreensão das drogas, em local já ser conhecido como ponto de venda de entorpecentes, a conduta de nervosismo do denunciado ao perceber a presença da viatura, a variedade e a localização de grande quantidade de drogas, bem como a forma de acondicionamento delas, em porções individuais, prontas para a venda, além da localização de petrecho destinado à pesagem de entorpecentes, não deixam dúvidas de que os narcóticos se destinavam ao tráfico. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Ademais, repise-se que o réu confessou os fatos (fls. 25), o que corrobora a versão incriminatória. Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta maus antecedentes e é primário (fls. 35/38). Ausentes agravantes e causas de aumento de pena. Já na terceira fase, cabe lembrar ser impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em a variedade, natureza e grande quantidade de drogas apreendidas, que revelam que o réu se dedicava a atividades criminosas, fazendo do narcotráfico meio de subsistência, verdadeiro profissional do tráfico. Tal circunstância também é provada pelas passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas. Assim, o acusado não preenche todos os requisitos legais da referida minorante. Pelos mesmos motivos, o regime prisional deverá ser o inicialmente fechado e se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até porque não está preenchido o

requisito objetivo para a substituição. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz. O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. Senão vejamos. I- REVISTA PESSOAL E RESIDENCIAL ILEGAL: A prova da materialidade delitiva foi obtida de forma ilícita, através de revista pessoal realizada em descompasso com a norma processual penal, acrescida de invasão ao domicílio do acusado. Conforme consta dos autos, os policiais optaram por abordar e proceder à revista do acusado tão somente pelo fato de ele ter “assustado” quando avistou a viatura e por, supostamente, ser “conhecido” dos quadros policiais pela venda de droga (sendo que o acusado se trata de pessoa primária, sem nenhuma passagem criminal). Unicamente em razão disso, os policiais optaram por revistá-lo. Narram os policiais que o acusado teria confessado que possuía mais entorpecentes e, então, optaram por entrar na residência (sem qualquer autorização registrada formalmente). O Código de Processo Penal elenca como requisito basilar para a realização da busca pessoal a existência de fundada suspeita. E fundadas suspeitas não se confundem com mera e qualquer suspeita ou exercício de achismo. Não se confundem com opiniões e preconceitos. A lei, neste ponto, é clara (art. 240, §2º). O mero nervosismo ao avistar a viatura policial não faz concluir pela fundada suspeita. Aliás, o réu não estava mantendo contato com qualquer pessoa, não havia denúncia formalizada contra ele e nada indicava que estivesse em situação de flagrância. Como se não bastasse, os policiais optaram por invadir a residência do acusado, supostamente com o seu consentimento, consentimento este que sequer foi registrado. Conforme recentemente decidido pelo STJ no HC n. 598.051: a) o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; & b) a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Dessa forma, sobre a forma do consentimento, deve ser expresso e jamais presumido, sendo que não há previsão legal de forma especial. Ainda, é necessário que aquele que consente tenha pleno conhecimento das circunstâncias e consequências da realização da busca domiciliar, bem como que isso seja documentado. No entanto, isso não aconteceu no caso concreto. Ainda que não exista tal previsão legal específica, tratando-se de medida que pode implicar a produção de prova contra o próprio morador que consente com a busca, para que ele decida de forma justa e válida se franqueará a entrada em sua residência, necessário que no mínimo lhe sejam esclarecidos seus direitos e o alcance da inviolabilidade do domicílio, bem como as consequências da realização da busca domiciliar. A mesma lógica e o mesmo cuidado são observados nos procedimentos de interrogatórios, tanto judicial quanto policial, a fim de garantir o direito da pessoa de não produzir prova contra si (deriva das previsões constitucionais – art. 5.º, LVII e LXII – e consagrado do Pacto de São José da Costa Rica, art. 8.º). No mais, o argumento de que o tráfico seria crime permanente não é temerário e não autoriza a invasão domiciliar. A esse respeito, decidiu o TJ-RS: “Dizer que nos crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrante se mantém, o que é dogmaticamente correto, não significa dizer que vaga suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes coloca o suspeito em estado de flagrância e, assim, afasta o direito à inviolabilidade do domicílio” (TJRS, Ap 0105880-83.2014.8.21.7000, rel. Des. Jayme Weingartner Neto, 3.ª Câmara Criminal, DJ 08.08.2014). No mesmo sentido, há julgados do TJRS que anularam buscas domiciliares, por não haver situação de flagrância apta a excepcionar a regra do art. 5.º, XI, da CF (Ap 03377639820138217000, rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, 3.ª Câmara Criminal, j. 07.08.2014; Ap 70051270478, rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, 3.ª Câmara Criminal, DJ 24.01.2013; Ap 70051282796, rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, 3.ª Câmara Criminal, DJ 24.01.2013). A

autorização para a violação do domicílio, nos casos de flagrante delito, depende de um estado de flagrância claro, constatado antes da invasão do domicílio e passível de demonstração posterior. As suspeitas, fundadas em relatos declarados ou ocultos, devem ser submetidas a prévia autorização judicial, mediante representação. Assim, no caso em discussão, todos os objetos encontrados devem ser desconsiderados e não se prestam a provar a materialidade delitiva, não havendo outra alternativa senão a absolvição do réu, com fundamento no disposto no art. 386, inc. VII, do CPP e em estrita observância ao disposto no art. 5º, art. LVI, da CF e art. 157 do CPP, evitando-se um edito condenatório nulo. II- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III- TESES SUBSIDIÁRIAS Caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer: i) fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, considerando que a culpabilidade do acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal; (ii) seja aplicada a atenuante da confissão espontânea; (iii) seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, já que presentes os requisitos legais; (iv) seja fixado o regime aberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, “c”, § 3º, do CP, bem como considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e da súmula nº 440 do E. STJ; (v) seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal; (vi) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) – art. 387, § 1º, do CPP. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. KEVIN WESLLEY PRESTES FERRAZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 17 h e 30 min, na Rua Mario Barros de Moura, n. 08, Vila Prado, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta e cinco microtubos de “cocaína”, com peso de 3,67 gramas; duzentas e oitenta e uma pedras de “crack”, com peso de 68,61 gramas; nove porções de “maconha”, com peso de 60,68 gramas; e cinco porções de “skunk”, com peso de 5,02 gramas. Notificado, fls. 106,

o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 110/111. A denúncia foi recebida, fls. 112/113, e o Réu, citado, fls. 131. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas presentes e realizou-se o interrogatório (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a absolvição. É o relatório. DECIDO. Afasto a preliminar. Durante policiamento ostensivo e preventivo, o Réu foi abordado em decorrência de comportamento e por estar em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, o qual gerou a fundada suspeita da posse de objetos ou substâncias ilícitas, que, por sua vez, autorizou a busca conforme os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal. Esse é o caso dos autos, pois a polícia tem a atribuição de prevenir e de reprimir delitos para a preservação da ordem pública. Neste sentido, entendimento do C. STJ: "HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE. 1. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. 2. Na espécie, ao contrário do que sustentado na impetração, o paciente não foi revistado simplesmente por ser do sexo masculino e estar no interior de um ônibus, mas sim porque, durante operação que objetivava combater roubos em coletivos, deixou para trás uma sacola que trazia consigo e dirigiu-se à porta do veículo, o que causou estranheza nos policiais que realizavam a abordagem, que pegaram o objeto para averiguação, oportunidade em que localizaram drogas em seu interior. 3. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente." (HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020). Segundo o art. 5º, inciso XI, a casa é asilo inviolável, salvo em caso de flagrante delito ou durante o dia, por determinação Judicial (grifo nosso). Portanto há autorização para ingresso em residências durante o dia ou noite em caso de flagrante delito. Segundo disposição do art. 283 "Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva". Oportuno ressaltar que os policiais não ingressaram na residência sem qualquer informação, de forma aleatória; tinham eles notícias de que o Réu vendia entorpecentes, e, no dia dos fatos, o Acusado foi abordado, e, com ele, houve apreensão de porções de drogas, oportunidade em que ele confessou a prática do tráfico de entorpecentes e disse que na casa havia outras porções. Assim, havia fundada suspeita para a abordagem e vistoria da casa, onde, de fato, encontraram entorpecentes destinados ao comércio, em situação de flagrante delito, na medida em que o crime de tráfico de entorpecentes é permanente. O caso concreto se amolda ao permissivo constitucional. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 19/22, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 02/03, no Laudo de Constatação, fls. 10/13, bem como no Exame químico-toxicológico n. 205.777/2021, fls. 89/93, contatando-se as presenças dos princípios ativos Cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC). Luciano Donizeti Rodrigues da Silva e Osny Benedito de Moraes Júnior, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu, o qual, ao ver a viatura, assustou-se, e, por ser pessoa conhecida nos meios policiais, foi abordado, oportunidade em que houve apreensão de um kit com 20 porções; o Acusado confessou o delito e apontou a existência de mais drogas na casa, e, de fato, os policiais localizaram, na residência, uma pochete com porções de "cocaína" e "skunk" e, na cozinha, 09 porções de "maconha" e balança de precisão. O Réu mostrou o local onde havia droga enterrada no quintal e os policiais desenterraram uma lata com 9 kits de "crack" e, por ser o quintal muito grande, com o emprego de um cachorro da Guarda Municipal, houve localização de mais 4 kits de drogas. Kevin Wesley Prestes Ferraz, Réu, ao ser interrogado, disse que as drogas eram suas e se destinavam à venda. Está arrependido pelo que fez e

somente assim agiu por necessidade. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a condenação é medida que se impõe. Com efeito, os policiais estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu, o qual trazia consigo um kit com 20 porções de "crack", e, posteriormente, na casa, houve apreensão de uma pochete com porções de "cocaína" e "skunk", e, na cozinha, existia 09 porções de "maconha" e uma balança de precisão. Após confissão do Réu e ante a notícia de que no quintal havia mais drogas, os policiais localizaram 09 kits de "crack" e, com o auxílio de um cão farejador, mais 04 kits. A diversidade, a quantidade, a forma de separação e a quantidade de porções demonstram claramente a finalidade mercantil. Ademais, havia apetrecho próprio do tráfico, a balança de precisão, utilizada para pesagem dos entorpecentes. Por fim, o Réu confessou e a confissão encontra amparo nas provas dos autos. Os policiais deram testemunhos firmes, coerentes, e descreveram de forma isenta os fatos como ocorreram. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais e agentes da lei, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo, guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, guardar e manter em depósito, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: O Réu é menor de 21 anos e confessou, logo faz jus às atenuantes. Todavia, na segunda etapa, as atenuantes não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". - Art. 68, do CP: Não há. Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa "empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo", pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização

da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar KEVIN WESLLEY PRESTES FERRAZ, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Decreto a perda dos bens apreendidos. Deixo de condenar o Réu nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu respondeu em liberdade ao processo, e, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 17 de fevereiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA